PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 1

DIREITO PENAL (DOGMÁTICA, TEORIA DO CRIME E POLÍTICA CRIMINAL)

Direito Penal

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas sabatinas de prova oral da Magistratura, o **Direito Penal** é explorado a partir da **Teoria do Crime e da Dogmática Penale**, testando a capacidade do candidato de conectar a estrutura analítica do delito a posições doutrinárias (Roxin, Jakobs, Ferrajoli, Zaffaroni, Welzel) e jurisprudenciais do STF e STJ.

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos pela banca compreendem:

1. **Conceito Analítico e Estrutura do Crime**: Teoria Tripartida vs. Bipartida, Tipicidade (formal, material e conglobante), Ilicitude e Culpabilidade.
2. **Iter Criminis e Formas de Extensão da Tipicidade**: Fases do crime, tentativa, atos preparatórios puníveis e "pontes de ouro" (desistência voluntária, arrependimento eficaz e posterior).
3. **Concurso de Pessoas e Teorias de Autoria**: Teoria Monista mitigada, Teoria Objetivo-Formal vs. Teoria do Domínio do Fato, autoria imediata/mediata, autoria de escritório e acessoriedade limitada.
4. **Nexo de Causalidade e Crimes Omissivos**: Equivalência dos antecedentes, causalidade adequada, imputação objetiva e a posição de garante (crimes omissivos próprios vs. impróprios).
5. **Política Criminal, Funcionalismo e Garantismo**: Funcionalismo moderado (Roxin) vs. sistêmico (Jakobs), Direito Penal do Inimigo, perigo abstrato, espiritualização do bem jurídico e Garantismo Penal Integral.

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Teoria Geral do Crime, Tipicidade e Ilicitude

- **Conceito e Estrutura do Delito**: *"Candidato, qual o conceito analítico de crime adotado no Brasil? Qual a diferença entre a Teoria Tripartida e a Teoria Bipartida, quais autores as sustentam e quais os elementos da culpabilidade para a corrente bipartida?"*.
- **Tipicidade Material e Conglobante**: *"Explique a divisão da tipicidade em formal, material e conglobante. Qual a contribuição de Eugênio Raul Zafarone para o tema e como o princípio da insignificância atua na tipicidade material?"*.
- **Teoria Indiciária da Ilicitude**: *"Em que consiste a teoria da 'ratio cognoscendi' no estudo da ilicitude? Como ela afeta o ônus da prova no processo penal e quais são as excludentes legais e supralegais?"*.
- **Princípio da Insignificância e Exceções**: *"Quais são os quatro vetores fixados pelo STF para a aplicação do princípio da insignificância? É possível sua incidência em caso de reiteração delitiva, nos crimes ambientais ou nos crimes militares?"*.

Eixo B: Iter Criminis, Tentativa e Institutos Acessórios

- **Fases do Iter Criminis e Atos Preparatórios**: *"Quais são as etapas do iter criminis? Os atos preparatórios são puníveis no ordenamento brasileiro? Dê exemplos de antecipação da tutela penal por política criminal."*.

- **Teorias da Execução**: *"Como o magistrado diferencia atos preparatórios de atos executórios? Quais são as teorias objetivo-formal, objetivo-individual e da hostilidade ao bem jurídico?"*.
- **Desistência Voluntária, Arrependimento Eficaz e Arrependimento Posterior**: *"Diferencie a desistência voluntária do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Qual a natureza jurídica de cada um deles e em qual momento do delito operam?"*.

Eixo C: Concurso de Pessoas, Autoria e Concurso de Crimes

- **Requisitos do Concurso de Pessoas**: *"Quais são os requisitos do concurso de pessoas e qual a teoria adotada pelo artigo 29 do Código Penal? Explicite a exceção pluralista."*.
- **Teorias de Autoria e Participação**: *"Diferencie autor de partícipe segundo as teorias Objetivo-Formal e do Domínio do Fato. O que é autoria de escritório no contexto das organizações criminosas?"*.
- **Unidade do Delito vs. Concurso em Crimes Contra a Dignidade Sexual**: *"No crime de estupro (art. 213 do CP), se o agente incide em mais de uma conduta (conjunção carnal e ato libidinoso) contra a mesma vítima, no mesmo contexto, ele responde por crime único (tipo misto alternativo) ou concurso material?"*.

Eixo D: Causalidade, Omissão e Imputação

- **Teorias do Nexo Causal**: *"Qual a teoria do nexo causal adotada no Código Penal? Como o artigo 13, § 1º, do CP trata as concausas supervenientes relativamente independentes e onde se insere a imputação objetiva de Roxin?"*.
- **Crimes Omissivos Próprios e Impróprios**: *"Qual a diferença entre crime omissivo próprio e impróprio (comissivo por omissão)? Quais as fontes da posição de garante no artigo 13, § 2º, do CP e cabe tentativa nos crimes omissivos?"*.

Eixo E: Escolas Penais, Funcionalismo e Política Criminal

- **Funcionalismo Moderado vs. Sistêmico**: *"Diferencie o funcionalismo racional-teleológico de Claus Roxin do funcionalismo sistêmico ou extremado de Günther Jakobs. O que é o Direito Penal do Inimigo?"*.
- **Espiritualização e Perigo Abstrato**: *"Em que consiste a espiritualização ou desmaterialização do bem jurídico penal? Os crimes de perigo abstrato são compatíveis com a Constituição Federal?"*.
- **Garantismo Penal**: *"Explique as vertentes do Garantismo Monocular de Luigi Ferrajoli em contraponto ao Garantismo Penal Integral sustentado pela doutrina contemporânea (Douglas Fischer)."*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Tentativa em Crime Omissivo Próprio**:
   - *A Pegadinha*: O examinador pergunta se cabe tentativa em crimes de omissão de socorro (art. 135 do CP).
   - *A Solução*: Não cabe tentativa em crimes omissivos próprios/puros, pois a omissão aperfeiçoa a consumação no exato instante da inércia, sendo unsubsistente. Cabe tentativa apenas nos omissivos impróprios (comissivos por omissão).
2. **Punibilidade dos Atos Preparatórios**:
   - *A Pegadinha*: Afirmar taxativamente que atos preparatórios nunca são puníveis.

- *A Solução*: Em regra são impuníveis, mas o legislador, por política criminal, autonomizou atos preparatórios como crimes independentes (ex.: Lei de Terrorismo - art. 5º da Lei 13.260/16; e Associação/Organização Criminosa - art. 288 do CP e art. 2º da Lei 12.850/13).

3. **Reincidência e Princípio da Insignificância**:
   - *A Pegadinha*: Dizer que a reincidência afasta automaticamente a insignificância em qualquer circunstância.
   - *A Solução*: A reincidência ou habitualidade delitiva inviabiliza em regra a insignificância (Súmula 599/STJ), mas o STF (ex.: Min. Gilmar Mendes) admite a aplicação excepcional no caso concreto quando a medida se mostrar socialmente recomendável e o furto for de valor ínfimo (ex.: furto de alimento por fome).
4. **Natureza Jurídica do Arrependimento Posterior**:
   - *A Pegadinha*: Confundir arrependimento posterior com exclusão de tipicidade (como na desistência e arrependimento eficaz).
   - *A Solução*: O arrependimento posterior (art. 16 do CP) é causa geral de diminuição de pena (causa de diminuição da 3ª fase da dosimetria), aplicando-se apenas a crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, com reparação do dano até o recebimento da denúncia.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Teoria do Crime e Culpabilidade (Teoria Tripartida vs. Bipartida)

Pergunta da Banca: *Candidato, o conceito analítico de crime exige a culpabilidade como elemento integrante do delito ou como mero pressuposto de aplicação da pena? Qual a posição dominante no Brasil e na jurisprudência dos Tribunais Superiores?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, prevalece na doutrina e na jurisprudência pátria a **Teoria Tripartida (ou Tritemática)** do crime, segundo a qual a culpabilidade é o terceiro substrato analítico do delito, ao lado do fato típico e da ilicitude."
2. **Fundamentação Legal e Conceitual**: "No ordenamento penal pátrio (artigos 19, 21, 22 e 26 do Código Penal), o crime é estruturado como uma conduta típica, ilícita e culpável. Para a corrente tripartida (sustentada por Bitencourt, Rogério Greco e Juarez Cirino), a culpabilidade é o juízo de reprovabilidade social que incide sobre o fato típico e ilícito, composto por três elementos normativos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa."
3. **Posição da Doutrina e Diferenciação**: "Em sentido diverso, a **Teoria Bipartida** (sustentada por Damásio de Jesus e Mirabete, com forte presença na doutrina paulista) conceitua o crime apenas como fato típico e ilícito, tratando a culpabilidade como mero pressuposto de aplicação da pena. Essa teoria fundamenta-se nas expressões legais como 'isento de pena', mas é criticada pela doutrina majoritária, pois a exclusão de qualquer substrato também gera a isenção de pena ou absolvição."
4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, no exercício da atividade jurisdicional, ao constatar a presença do fato típico e da ilicitude, cabe ao magistrado verificar se o agente possuía higidez mental e capacidade de conformação à norma para a prolação do decreto condeno, aplicando o sistema vicariante em caso de inimputabilidade."

Modelo B — Iter Criminis (Desistência Voluntária vs. Arrependimento Eficaz)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, diferencie a desistência voluntária do arrependimento eficaz e esclareça qual a consequência jurídica aplicada pelo Código Penal a ambos os institutos.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a diferença ontológica reside no momento de execução da conduta: na **desistência voluntária**, o agente interrompe a execução quando ainda dispunha de meios para prosseguir; no **arrependimento eficaz**, o agente exaure os meios executórios, mas atua positivamente para impedir a produção do resultado consumativo."
2. **Fundamentação Legal**: "Ambos os institutos estão positivados no **artigo 15 do Código Penal**, denominados pela doutrina de 'ponte de ouro' da política criminal. A consequência jurídica expressa na norma é que o agente **responde apenas pelos atos já praticados**."
3. **Análise de Natureza Jurídica**: "Doutrinariamente (conforme lição de Nélson Hungria e Claus Roxin), a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz é de **causa de exclusão atípica (ou atipicidade relativa do crime inicialmente intentado)**. Trata-se de uma causa de adequação típica indireta por atipicidade da tentativa originária."
4. **Fechamento Institucional / Aplicação Prática**: "Assim, em um caso concreto de disparos de arma de fogo onde o réu, dispondo de mais munições, cessa voluntariamente os disparos (desistência) ou socorre a vítima e evita sua morte (arrependimento eficaz), o magistrado não o pronunciará nem condenará por tentativa de homicídio, desclassificando a conduta para lesão corporal consumada, preservando a justa medida da resposta penal."

Modelo C — Concurso de Pessoas e Teoria do Domínio do Fato

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, qual a teoria adotada no Brasil para definir a autoria e a participação no concurso de pessoas? Em que consiste a Teoria do Domínio do Fato e onde ela se aplica no direito penal econômico e nas organizações criminosas?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o Código Penal brasileiro adota, em seu artigo 29, a **Teoria Monista (ou Unitária) mitigada**, aplicando como regra para a conceituação de autor a **Teoria Objetivo-Formal**, complementada pela **Teoria do Domínio do Fato** no âmbito da macrocriminalidade."
2. **Fundamentação Legal e Doutrinária**: "Pela Teoria Objetivo-Formal, autor é aquele que executa o núcleo do verbo do tipo penal, e partícipe é quem presta auxílio material ou moral (instigação/induzimento) sem executar a conduta típica (adotando-se a Teoria da Acessoriedade Limitada). Todavia, a Teoria do Domínio do Fato (desenvolvida por Hans Welzel e aprofundada por Claus Roxin) conceitua autor como aquele que detém o controle final da ação, decidindo sobre o 'se', o 'como' e o 'quando' do delito."
3. **Jurisprudência dos Tribunais Superiores**: "O STF (no julgamento da AP 470) e o STJ consolidaram que a Teoria do Domínio do Fato é plenamente aplicável para responsabilizar os detentores do domínio funcional da conduta e os autores intelectuais no âmbito de **estruturas organizadas de poder (autoria de escritório)**, conforme prevê o art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013. Ressalto, contudo, que a posição de chefe ou dirigente não autoriza a responsabilidade penal objetiva, exigindo-se a comprovação do dolo e do nexo de imputação."
4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, na prolação da sentença penal envolvendo organizações criminosas, o magistrado individualizará a conduta do mandante/autor de escritório e dos executores materiais, fundamentando a dosimetria da pena sob a égide do artigo 59 do CP de forma proporcional ao grau de culpabilidade e domínio funcional exercido por cada qual."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 1

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Execução Imediata no Júri	Dependia de pena fixada igual ou superior a 15 anos de reclusão (Pacote Anticrime).	**STF (Tema 1068/RG)**: A soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF) autoriza a **execução imediata da pena** imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do *quantum* de pena.
Legítima Defesa da Honra	Aceita como tese absolutória em feminicídios no Tribunal do Júri.	**STF (ADPF 779)**: Declarada **inconstitucional** por violar a dignidade humana, a igualdade de gênero e a vida. Sua sustentação gera a nulidade do ato.
Responsabilidade da PJ por Crime Ambiental	Exigia a "Teoria da Dupla Imputação" (imputação concomitante da pessoa física e jurídica).	**STF e STJ**: **Abandono definitivo da dupla imputação**. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente por crimes ambientais de forma autônoma (art. 225, §3º, CF).
Insignificância e Reincidência	A reincidência impedia taxativamente a aplicação do princípio da insignificância.	**STF**: Admite-se a **aplicação mitigada/excepcional** da insignificância ao reincidente no caso concreto, se a medida for socialmente recomendável e o bem for de valor ínfimo.
ANPP e Retroatividade	Discutia-se a aplicação apenas a inquéritos antes do oferecimento da denúncia.	**STF (HC 185.068)**: O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) retroage aos processos em andamento **até o trânsito em julgado** da condenação.